

1500389-76.2022.8.26.0603
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA
Comarca: Birigui
Foro: Foro de Birigui
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 12/09/2022
... os fatos, para sua melhor elucidação.

Tráfico de drogas.

A autoria e a materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas restaram comprovadas. Nesse sentido, temos: o auto de prisão em flagrante de fl. 01; o recibo de entrega de preso de fls. 02/03; a nota de culpa de fl. 09; o boletim de ocorrência acostado às fls. 15/18; o auto de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Birigui
Foro de Birigui
1ª Vara Criminal
Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500389-76.2022.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500389-76.2022.8.26.0603
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2061633/2022 - DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 23403680 - DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 2061633 - DEL.POL.BIRIGUI
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CLEBER DOS SANTOS
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

S E N T E N Ç A

Processo nº. 1500389-76.2022.8.26.0603 (Controle nº 548/2022).

VISTOS.

CLÉBER DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi preso em flagrante delito, denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 06 de março de 2022, por volta das 00h30min, na Rua Saudades, nº 1685, Centro, cidade e comarca de Birigui, trazia consigo e tinha em depósito um total de 72 (setenta e dois) eppendorfs de cocaína, pesando 64,58 gramas, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação provisória de fl. 24 e laudo toxicológico definitivo de fls. 122/124.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo, porém na Rua Manoel Lino Filho, nº 283, Toselar, nesta cidade e comarca de Birigui, CLÉBER DOS SANTOS, possuía e mantinha sob sua guarda 10 (dez) munições de calibre .38 intactas e 10 (dez) munições de calibre .22 intactas, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, conforme laudo pericial de fls. 106/110.

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado para apresentar defesa escrita (fl. 155), cuja peça foi juntada às fls. 156/165, sobrevivendo o recebimento da denúncia em 01 de junho de 2022 (fls. 196/198), com a citação pessoal do acusado (fl. 229). Na instrução, foram colhidos os depoimentos de 02 (duas) testemunhas arroladas em comum, sobrevivendo, ao final, o interrogatório do acusado (fls. 297/298).

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do acusado, nos termos da denúncia (fls. 302/308).

Por outro lado, a defesa, em preliminar, alegou ausência de justa causa. Em caso de condenação, requereu a aplicação da pena no mínimo legal; aplicação do parágrafo 4º do art. 33 da lei de drogas; fixação do regime aberto; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; reconhecimento da detração penal; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; o direito de o acusado recorrer em liberdade; e a revogação da prisão preventiva (fls. 311/317).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de condutas que, em tese, estariam a configurar os delitos de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06) e posse ilegal de munição de uso permitido (art. 12, da Lei nº. 10.826/03).

De início, não há que se falar em absolvição sumária, por ausência de justa causa. Os pressupostos processuais e os requisitos para o recebimento da denúncia estão presentes, não havendo que se falar em falta de justa causa para a ação penal, que contém todas as condições para sua instauração e seu prosseguimento, de acordo com o que se apurou no inquérito policial.

No mérito, a ação penal é totalmente procedente.

Ao término da instrução criminal, e após uma atenta análise das provas reunidas nos autos, não se pode deixar de reconhecer que a materialidade e autoria dos fatos descritos na denúncia ficaram satisfatoriamente comprovadas.

Considerando que a presente ação penal apura mais de um delito, envolvendo o mesmo réu, passo a analisar separadamente os fatos, para sua melhor elucidação.

Tráfico de drogas.

A autoria e a materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas restaram comprovadas.

Nesse sentido, temos: o auto de prisão em flagrante de fl. 01; o recibo de entrega de preso de fls. 02/03; a nota de culpa de fl. 09; o boletim de ocorrência acostado às fls. 15/18; o auto de exibição e apreensão encartado às fls. 20/21; o laudo de constatação prévia de fl. 24; depósito judicial de fl. 98; os laudos periciais de fls. 102/105, 106/110 e 122/124; o relatório policial de fls. 125/126; os depoimentos das testemunhas; e a confissão apresenta pelo acusado em juízo. Na fase policial, o acusado negou que o entorpecente lhe pertencia (fls. 07/08).

Em Juízo, o acusado confessou a autoria do crime. Disse que foi abordado no posto de combustível, sendo localizado porções de cocaína em seu bolso, que seriam para venda. Afirmou que os R\$ 400,00 (quatrocentos reais) eram provenientes do seu trabalho de entregador. Informou aos policiais que, em sua residência, tinha mais drogas, que eram destinadas para venda, além de munições de arma de fogo. O dinheiro apreendido na residência, disse que pertencia a sua companheira. Por fim, disse ser usuário de drogas (fls. 297/298).

A confissão livre e espontânea prestada no processo, serve como importante elemento de convicção para evidenciar a autoria e amparar a condenação, quando encontrar sustentação nos demais elementos de convicção produzidos.

De fato, no caso, a confissão do réu encontrou total respaldo nas demais provas carreadas aos autos.

Com efeito, as testemunhas Welisson Luiz de Oliveira e William de Santana, policiais militares, ouvidos em ambas as fases da persecução penal, disseram que avistaram um veículo Gol, cujo condutor, quando avistou a proximidade da viatura, acelerou o veículo e entrou no posto de combustível. Abordaram o acusado e localizaram na sua blusa um pote de bala "Mentos", contendo em seu interior 30 eppendorfs de cocaína, e o valor de R\$ 370,00 em notas diversas. Indagado, o acusado disse que trabalhava como entregador de lanches e admitiu que, quando realizava a entrega dos lanches, também fazia a entrega de entorpecentes, praticando o tráfico de drogas. O acusado disse ainda que, em sua residência, haveria mais drogas e dinheiro. No local, o acusado franqueou a entrada e indicou onde estava as drogas e o dinheiro, sendo localizados mais 42 eppendorfs com cocaína, 10 munições de calibre .38 intactas, 10 munições de calibre .22 intactas e R\$ 1.645,00 reais em notas diversas, bem como 138 eppendorfs vazios. Neste momento, o filho do acusado teria dito que a arma de seu pai ficava na residência de seu avô, sobre o guarda-roupa de um dos quartos. Foram até o local e nada de ilícito foi encontrado (fls. 02/03, 04/05 e 297/298).

Os policiais confirmaram que localizaram os entorpecentes e que o réu confessou que os comercializava.

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Tais depoimentos somente não terá valor quando se evidenciar o interesse dos servidores na investigação penal, e quando suas declarações não encontrarem suporte em outros elementos probatórios idôneos.

Importante salientar que não existe qualquer circunstância que justificasse o interesse dos policiais em prejudicar o acusado, ou em imputar falsamente a ele a prática de conduta definida como crime, sobretudo porque ele não apontou nada que justificasse essa circunstância.

Não se pode olvidar que foram apreendidos eppendorfs vazios na casa do acusado, o que só vem reforçar que ali se praticava o tráfico, haja vista que, como é cediço, eppendorfs desse tipo são utilizados para quantificar as porções que serão vendidas.

No que se refere aos entorpecentes apreendidos, a perícia apontou que consistem realmente em "cocaína" (exame químico-toxicológico de fls. 122/124).

De outra parte, a quantidade dos entorpecentes apreendidos, ou seja, 64,58 gramas de cocaína, as circunstâncias da abordagem do réu (réu acelerou ao avistar a viatura), a forma de acondicionamento da droga (distribuídas em porções prontas para o comércio); a apreensão de eppendorfs vazios e dinheiro; e a confissão do acusado, estão a caracterizar a traficância.

Nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou tenha em depósito para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado. No caso, o réu foi denunciado porque trazia consigo e tinha em depósito os entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a venda a terceiros.

O simples de fato de a droga não ter sido apreendida em grande quantidade, por si

só, não afasta a tipificação do crime de tráfico. Aliás, atualmente, os traficantes vêm utilizando desse modo de agir (distribuição de pequenas porções entre vários entregadores), a fim de dificultar a apreensão da droga e a caracterização do crime de tráfico.

Relevante apontar que o réu não arrolou sua companheira como testemunha, de quem, segundo ele, seria o dinheiro apreendido na residência, assim como desistiu das testemunhas, dentre as quais o empregador de quem disse ter recebido o dinheiro apreendido como de seu trabalho, providências essas que seriam de fácil consecução, caso fossem verdadeiras as narrativas apresentadas.

Portanto, a prova coletada nos autos é substancial e convincente, ficando evidente a autoria do crime por parte do réu, no crime ora apurado.

Assim, além da robusta prova acima analisada, há indícios mais que suficientes para a prolação de decreto condenatório. Aliás, neste ponto, tratando-se de delito, na maioria das vezes, praticado às escondidas, não se pode abrir mão dos indícios para o estabelecimento da verdade real. E a definição de indício vem estabelecida no próprio Código de Processo Penal, no artigo 239. Com isso, constata-se que o juiz formará a sua convicção na livre apreciação da prova, e, diante do nosso sistema processual, o indício é o fato provado que, por sua ligação íntima com o fato probando, autoriza a concluir algo sobre este, até porque os indícios estão inscritos no título da prova, e, assim, a autoria do delito, pelo sistema do livre convencimento, pode ser demonstrada, validamente, pela força probante dos indícios. Sendo assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local indicados na denúncia, o acusado trazia consigo e tinha em depósito 64,58 gramas de cocaína, substância entorpecente determinante de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para entrega a consumo de terceiros.

A conduta do réu encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, exclua a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade.

Posse ilegal de munição de uso permitido.

Quanto a esse delito, a ação também é procedente, porque a autoria e a materialidade também restaram comprovadas. Nesse sentido, temos: o auto de prisão em flagrante de fl. 01; o recibo de entrega de preso de fls. 02/03; a nota de culpa de fl. 09; o boletim de ocorrência acostado às fls. 15/18; o auto de exibição e apreensão encartado às fls. 20/21; o laudo pericial de fls. 106/110; o relatório policial de fls. 125/126; os depoimentos das testemunhas; e a confissão apresenta pelo acusado em juízo.

Na fase policial, o acusado negou que as munições lhe pertenciam (fls. 07/08).

Em Juízo, o acusado confessou a autoria do crime, dizendo que as munições encontradas em sua residência lhe pertenciam (fls. 297/298).

A confissão livre e espontânea prestada no processo, serve como importante elemento de convicção para evidenciar a autoria e amparar a condenação, quando encontrar sustentação nos demais elementos de convicção produzidos.

De fato, no caso, a confissão do réu encontrou total respaldo nas demais provas carreadas aos autos.

Com efeito, as testemunhas Welisson Luiz de Oliveira e William de Santana, policiais militares, ouvidos em ambas as fases da persecução penal, disseram que, na casa do acusado, este franqueou a entrada e indicou onde estavam as 10 munições de calibre .38 intactas e 10 munições de calibre .22 intactas (fls. 02/03, 04/05 e 297/298).

Reitero, aqui, os argumentos acima expostos sobre o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais.

Por fim, o laudo pericial de fls. 106/110 apurou que os cartuchos estavam aptos para realizar disparos.

Sendo assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local indicados na denúncia, o acusado possuía e mantinha sob sua guarda, 10 (dez) munições de calibre .38

intactas e 10 (dez) munições de calibre .22 intactas, de uso permitido, sendo que o fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A conduta do réu encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 12, caput, da Lei 10.826/03. Neste ponto, não se pode deixar de mencionar que, tratando-se de crimes de perigo abstrato, desnecessária a perquirição de eventual dano que poderia ser causado pelas munições apreendidas. Da mesma forma, o legislador não fez distinção acerca da quantidade de munição, nem tampouco da propriedade do cartucho ou de eventual existência de arma de fogo. Inexistem causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência dos delitos e passo a aplicar as penas, separadamente.

Das penas.

Posse ilegal de munição de uso permitido.

O acusado ostenta maus antecedentes (fls. 318/319 - Processo nº 0001557-78.2006.8.26.0077 e fl. 320 - Processo nº 0012349-28.2005.8.26.0077), razão pela qual as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal não lhe são favoráveis e autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), resultando em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual retorno a pena ao patamar mínimo, ou seja, 01 (um) ano de detenção, e pagamento de 10 (dez) dias-multa. No mais, não há circunstâncias agravantes ou outras atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas. Torno, pois, definitiva a pena em 01 (um) ano de detenção, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Tráfico de drogas.

Pelos mesmos motivos já expostos acima quando da fixação da pena em relação ao crime de posse ilegal de munição de uso permitido (maus antecedentes - fls. 318/319 - Processo nº 0001557-78.2006.8.26.0077 e fl. 320 - Processo nº 0012349-28.2005.8.26.0077), fixo a pena-base acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual retorno a pena ao patamar mínimo, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. No mais, não há circunstâncias agravantes ou outras atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, não vislumbro a existência de causas de aumento ou diminuição de pena. Não há como se aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, porque o réu ostenta maus antecedentes.

Torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06).

Observo que, diante dos diferenciados tipos de pena privativa de liberdade (reclusão e detenção), não poderá ser aplicado o concurso material, com a soma das penas. Fixo, assim, cada pena separadamente, observando-se, na fase de execução, o disposto no artigo 69, caput, 2ª parte, do Código Penal.

Quanto ao tráfico de drogas, diante da gravidade da conduta, mesmo levando-se em conta a detração penal disposta na Lei nº 12.736/12 (art. 2º, que acrescentou o § 2º ao art. 387 do CPP), a pena deve ser cumprida no regime inicial fechado, obrigatoriamente, pois se trata de crime equiparado a hediondo, conforme estatuído no art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90.

Ademais, infere-se inviável, de igual sorte, a alteração do regime prisional, na hipótese, com esteio no lapso que perdurou a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito da real situação carcerária do acusado, isto é, se não registra

outras condenações ou prisões processuais, nem quanto ao seu comportamento e conduta no cárcere, a revelar não existirem elementos seguros para a correta análise, nesta seara e de pronto, quanto a eventual direito à detração penal, emergindo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, à míngua de informações concretas.

Quanto ao crime de posse de munição, em razão da quantidade da pena ora fixada, ainda que ostente maus antecedentes, poderá o réu cumpri-la em regime aberto. Fixo cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, ante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do réu.

Como verá doravante, estão presentes os requisitos da custódia cautelar, devendo o acusado continuar a responder preso por este processo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para:

1) CONDENAR CLEBER DOS SANTOS ao cumprimento pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal (art. 49 e parágrafos do CP), dando-o como incurso nas penas do artigo 12 da Lei nº. 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).

Apesar de preenchidos os requisitos do artigo 44, incisos I e II, do Código Penal (pena não superior a quatro anos e réu não reincidente em crimes dolosos), entendo que o requisito do inciso III do mesmo artigo não se mostra presente, porque o réu ostenta maus antecedentes e, além da munição, também mantinha sob sua guarda cocaína, para fins de tráfico de drogas, indicando que, no caso em especial, a substituição do artigo 44 do Código Penal não é suficiente para a repressão e prevenção do delito, vez que admitir um traficante, que possuía munição de arma de fogo, prestar serviços em escolas e outras entidades públicas, colocaria em risco as pessoas que delas se utilizam, inclusive crianças inocentes, o que, de forma alguma, se pode admitir.

2) CONDENAR CLEBER DOS SANTOS, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado (art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação da Lei nº 11.464/07), e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06), dando-o como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Consigno que o acusado ficou preso cautelarmente desde 06/03/2022 até a presente data, período sobre o qual fica reconhecida a detração penal, para fins de cumprimento do restante da pena, nos termos do que dispõe o artigo 1º da Lei nº 12.736/12.

Deve, no entanto, a Serventia, ao expedir a Carta de Guia, atentar para se consignar a condenação total constante do dispositivo acima, com as observações consignadas no parágrafo anterior (detração penal).

Quanto a este crime (tráfico), deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por entender incabível tal providência.

Não obstante o julgamento do Habeas Corpus n. 0094294-30.2012.8.26.0000, pelo Supremo Tribunal Federal, no qual se entendeu por inconstitucional a vedação à substituição por penas restritivas de direitos para o crime de tráfico, por afronta ao princípio da individualização da pena, até então não se trata de decisão proferida com efeito erga omnes.

Foi editada a Resolução nº 5/2012, do Senado Federal, que, nos termos do artigo 52, inciso X, da Constituição Federal, suspendeu a execução de parte do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, que vedava de forma abstrata (sem análise do caso concreto) a conversão em penas restritivas de direito, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo em decisão no Habeas Corpus já mencionado acima.

Com a mencionada Resolução, não se pode mais afirmar que o efeito do julgamento daquele habeas corpus não é para todos. Entretanto, a intenção do Supremo Tribunal Federal, ao decidir desta forma, e o Senado Federal, ao editar a resolução, foi somente deixar à prudente análise do magistrado do caso concreto se o réu tem ou não direito a ter a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, e não que essa substituição seja admitida em qualquer caso de tráfico de drogas, indistintamente. Pensar assim seria um contrassenso.

Confira, neste sentido, decisão proferida em Apelação Criminal que analisou sentença proferida por este juízo:

"... Inviável, nesse passo, a pretendida substituição carcerária por restritivas de direito, porque, embora o teor da recente Resolução nº. 5/2012 do Senado Federal, fundada na decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos do Habeas Corpus, nº. 97.256/RS – mencionado nas razões recursais –, em controle difuso de constitucionalidade, in casu, permanece impossível, data vênua, a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, ou mesmo a concessão de sursis, pois o crime de tráfico de entorpecentes revela a gravidade peculiar que desestabiliza a vida em sociedade e fere de morte a saúde pública, pois enquanto fomenta, simultânea e irremediavelmente – até as pedras estão cansadas de saber –, a violência, a destruição de lares e das famílias e a prática de n crimes, sobretudo para o fim de viabilizá-lo, tanto assim que, por força de norma constitucional, é assemelhado aos delitos hediondos, cuja pena deve ser cumprida no regime prisional inicial fechado, determinação esta que se mostra incompatível com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou com a suspensão condicional da pena, de modo que não se consegue compreender ou avaliar, por mais que se esforce, qual seria a pena substitutiva ou as condições do sursis adequadas ao traficante, emergindo sintomático que – até o momento – jurista sério algum tenha ousado sugerir-las..." (TJ-SP, Apelação Criminal nº 0009435-15.2010.8.26.0077, 5ª Câmara Criminal, rel. Des. Juvenal Duarte, j. 19.04.2012).

Ainda no mesmo sentido, confira julgamento proferido em processo que tramitou por essa comarca de Birigui:

"Também não faz jus a apelante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados a tráfico de drogas é incompatível com a gravidade e as circunstâncias em que o crime é cometido, não havendo qualquer tipo de violação ao princípio da individualização da pena.

Este entendimento deve prevalecer, notadamente ao se considerar a vedação expressa trazida pelo artigo 44 da Lei de Drogas.

Com efeito, o benefício consistente na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos tem por objetivo primordial o de possibilitar a ressocialização de indivíduos de baixa periculosidade, que praticaram delitos de pequeno grau de lesividade social.

Traficantes de substâncias entorpecentes, sejam de pequeno, médio ou grande porte, não tem o perfil de iniciar o cumprimento de sua pena que não mediante encarceramento. Mesmo o pequeno traficante merece uma punição severa. Basta que a venda de drogas seja realizada uma única vez, para que cause uma série de malefícios ao consumidor, as quais virão a repercutir a toda a coletividade. Ressalta-se que uma das exigências previstas no artigo 44, inciso III, do Código Penal, para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é a de que os motivos e as circunstâncias indiquem como suficiente tal medida, para a repressão do agente da conduta delituosa.

Conforme já fundamentado, tal benefício não se coaduna com as graves consequências que a mercancia de substâncias entorpecentes causa, não só ao usuário, com uma rápida deterioração da sua saúde física e mental, mas também ao corpo social (deseestrutura familiar, estímulo à prática de outros crimes, como homicídios, latrocínios, extorsões etc.).

Muito embora o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do "Habeas Corpus" nº 97256/RS, tenha expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no § 4º, do artigo 33, da Lei 11343/06, é de se ressaltar que tal decisão não possui o erga omnis.

E mesmo a resolução nº 5 do Senado Federal, de 15 de fevereiro de 2012, que suspendeu a eficácia da referida expressão, não acarreta direito subjetivo do agente que praticou o grave delito do tráfico de entorpecentes a tal conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Frise-se, ainda, que o artigo 44 da Lei de Drogas mantém tal vedação ao crime de

tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput. Considerando que o § 4º é tão somente uma causa de diminuição do delito previsto no caput – e não um crime autônomo –, é possível concluir que a vedação a ele também se aplica. Neste aspecto, ensina Guilherme de Souza Nucci que “(...) o fato de haver sido prevista uma causa de diminuição de pena para o traficante primário, de bons antecedentes, sem outras ligações criminosas, não afasta a tipificação da sua conduta como incursas no artigo 33, caput e § 1º, que são consideradas similares a infrações penais hediondas, como se pode observar pelas proibições enumeradas no artigo 44 da Lei 11343/06. Salienta-se, ademais, o cuidado legislativo em vedar a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, típica opção de política criminal para o tráfico ilícito de drogas. Não se pode criar uma nova infração penal, a partir da mera aplicação de causa de diminuição de pena. Por isso, o tráfico ilícito de drogas será sempre considerado equiparado a hediondo, ainda que comporte, por opção legislativa, pena mais branda, quando os requisitos do § 4º estiverem presentes” (in “Leis Penais e Processuais Penais Comentadas”, 5ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2010, p.372). Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau” (Apelação Criminal nº 0002364-20.2014.8.26.0077. Rel. Toloza Neto).

Não bastassem esses argumentos, anoto ainda que o acusado possui maus antecedentes e a pena fixada ultrapassa quatro anos, o que afasta de vez a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O acusado deverá continuar a responder preso por este processo, pois sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 72/74), ocasião em que foram expostos os fundamentos necessários para a custódia cautelar, os quais ficam aqui reiterados, como razão de decidir, assim como àqueles expostos na decisão de fls. 192/193, que indeferiu o pedido de revogação da prisão.

Ademais, continuam presentes os requisitos que recomendam a custódia cautelar do acusado, mormente porque praticou delito equiparado aos hediondos.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, com fundamento nos artigos 59 da Lei nº 11.343/06, c.c. o § 4º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90, acrescentado pela Lei nº 11.464/07.

A incineração da droga apreendida já foi determinada e realizada (fls. 72/74, 189 e 191), razão pela qual nada há a ser decidido a respeito.

Restou provada a procedência ilícita do dinheiro apreendido (fl. 20/21 - R\$ 2.015,00), razão pela qual não há como se deixar de reconhecer que é produto do tráfico de entorpecente praticado pelo acusado. Logo, com fundamento nos artigos 91, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, e 63 da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento do dinheiro apreendido e depositado nos autos à fl. 98.

Após o trânsito em julgado, comunique-se o “Senad” quanto ao perdimento supra determinado, instruindo o ofício com cópias do auto de exibição e apreensão, da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Quanto aos eppendorfs vazios, diante da natureza dos objetos, entendo não ser caso de perda, mas sim destruição imediata, a qual fica desde já determinada, expedindo-se o necessário e comunicando-se a Sala de Armas e Objetos Apreendidos, independentemente do trânsito em julgado da presente.

Oficie-se à Delegacia de Polícia de origem, informando sobre a destruição dos objetos e perdimento do dinheiro apreendidos, instruindo-se o ofício com as cópias. No tocante à munição apreendida (fls. 20/21), já foi elaborado o laudo pericial e as partes dele já tomaram ciência. Não há notícia de que a munição pertença a terceiro de boa-fé, para fins de notificação quanto ao interesse em sua restituição, além do que a guarda da munição não é imprescindível para o esclarecimento dos fatos apurados no processo (art. 1º, § 1º, Res. 134/11 do CNJ). Portanto, com fundamento no artigo 1º, caput, da Resolução nº 134/11 do Conselho Nacional de Justiça, c.c. o artigo 3º do Provimento nº 1924/11 do Conselho Superior da Magistratura, determino o encaminhado da munição ao Comando do Exército, para

destruição, nos termos do artigo 25 da Lei nº. 10.826/03, independentemente do trânsito em julgado.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do réu.

Com o trânsito em julgado da presente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, nos termos do artigo 28 da Resolução nº 23.399/13 do TSE, instruindo o ofício com cópias da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Custas, na forma da lei.

P. R. I.

Birigui, 12 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA